

予備独自問題 H30-25

(配点: 3)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 刑事訴訟法第321条第3項所定の書面の作成主体は「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とされているところ、火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有する者は、私人であっても同項の作成主体に準ずるものと解されるから、同人の作成した燃焼実験報告書についても、同項の書面に準ずるものとして、同項により証拠能力を認めることができる。
- イ. 捜査官が、被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして、被疑者に犯行状況について再現させた結果を記録した実況見分調書の要証事実が、再現されたとおりの犯罪事実の存在と解されるときは、このような内容の実況見分調書の証拠能力については、刑事訴訟法第326条の同意が得られない場合には、同法第321条第3項所定の要件を満たす必要があることはもとより、被告人である再現者の供述の録取部分については同法第322条第1項所定の要件を、写真部分については署名押印を除く同項所定の要件を、それぞれ満たす必要がある。
- ウ. 刑事訴訟法第323条第2号の「業務の通常過程において作成された書面」に該当するか否かは、その書面自体だけから判断されなければならない、その作成者の証言等関係証拠を考慮に入れて判断することは許されない。
- エ. 犯行の状況を撮影したいわゆる現場写真は、非供述証拠に属し、当該写真自体又はその他の証拠により事件との関連性を認め得る限り証拠能力を具備するものであって、これを証拠として採用するためには、必ずしも撮影者らに現場写真の作成過程ないし事件との関連性を証言させることを要しない。
- オ. 刑事訴訟法第328条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面(同法が定める要件を満たすものに限り)、同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られる。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

No289	伝聞例外	正答率
予備H30-25	正解	63%

ア 誤っている

最決平20.8.27(百選83事件)は、消防士として15年間の勤務経験があり、通算約20年にわたって火災原因の調査、判定に携わってきた私人が、消防学校の依頼を受けて行った燃焼実験の結果を報告した報告書抄本について、321条3項準用により証拠能力を認めることができるかが争われた事案において、「本件報告書抄本のような私人作成の書面に同項を準用することはできない」としている。その理由として、判例は、「同項所定の書面の作成主体は『検察官、検察事務官又は司法警察職員』とされているのであり、かかる規定の文言及びその趣旨」を挙げている。なお、同判例は、321条3項の準用は認めなかったものの、「作成者は、火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有するものであり、本件報告書抄本は、同人が、かかる学識経験に基づいて燃焼実験を行い、その考察結果を報告したものであって、かつ、その作成の真正についても立証されていると認められるから、結局、本件報告書抄本は、321条4項の書面に準ずるものとして同項により証拠能力を有する」としている。

イ 正しい

最決平17.9.27(百選82事件)は、犯行状況等の再現結果を記録した実況見分調書の証拠能力が争われた事案において、「本件両書証は、捜査官が、被害者や被疑者の供述内容を明確にすることを主たる目的にして、これらの者に被害・犯行状況について再現させた結果を記録したものと認められ、立証趣旨が『被害再現状況』、『犯行再現状況』とされているにもかかわらず、実質においては、再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものと解される。このような内容の実況見分調書や写真撮影報告書等の証拠能力については、刑訴法326条の同意が得られない場合には、同法321条3項所定の要件を満たす必要があることはもとより、再現者の供述の録取部分及び写真については、再現者が被告人以外の者である場合には同法321条1項2号ないし3号所定の、被告人である場合には同法322条1項所定の要件を満たす必要があるというべきである。もっとも、写真については、撮影、現像等の記録の過程が機械的操作によってなされることから前記各要件のうち再現者の署名押印は不要と解される」としている。

ウ 誤っている

最決昭61.3.3は、漁船団の取決めにより各漁船から発せられる操業位置等についての無線通信を機械的に記録した書面が323条2号の書面に該当するかが争われた事案において、「本件受信記録の原本は、それ自体だけでは刑訴法323条2号にいう『業務の通常の過程において作成された書面』であることが必ずしも明らかではないけれども、その作成者の証言等関係証拠をも併せて検討すると、……『業務の通常の過程において作成された書面』に該当する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、323条各号の予定する書面であるかどうかは、通常は、その書面の表題、形式、内容など書面自体から明白な部分が多いが、作成状況や書面の成立過程に関する作成者等の証言等を判断資料とすることも許されるということを挙げている。

エ 正しい

最決昭59.12.21(百選87事件)は、「犯行の状況等を撮影したいわゆる現場写真は、非供述証拠に属し、当該写真自体又はその他の証拠により事件との関連性を認めうる限り証拠能力を具備するものであって、これを証拠として採用するためには、必ずしも撮影者らに現場写真の作成過程ないし事件との関連性を証言させることを要するものではない」としている。

オ 正しい

最判平18.11.7（百選85事件）は、328条により許容される証拠の範囲が争われた事案において、「刑訴法328条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面（刑訴法が定める要件を満たすものに限る。）、同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られる」としている。その理由として、判例は、「刑訴法328条は、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述が、別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより、公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり、別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については、刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である」ということを挙げている。

以上により、誤っている記述はアとウであり、したがって、正解は肢1となる。

